

1500728-15.2022.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500728-15.2022.8.26.0545

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2194598/2022 - DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 26204217 -

DEL.SEC.BRAG.PTA PLANTÃO, 2194598 - DISE- DEL.SEC.BRAGANÇA PTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SUSAN PEREIRA DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

SUSAN PEREIRA DA SILVA foi denunciada como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia 18 de julho de 2022, na rua Monsenhor Tito José Felice, nº 270, Apto 23, bloco 1, Condomínio Nicola Cortez 6, Residencial Hípica

Jaguari, nesta cidade e Comarca, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, 184 papé debates de cocaína, 79 pedras de crack, 600 porções de cocaína, 114 papé debates de maconha e três tijolos de maconha, pesando aproximadamente 1640 gramas, além de dois galões de lança perfume, com 08 litros, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Devidamente notificada, a acusada apresentou defesa preliminar às fls. 91/92.

Recebida a denúncia aos 29 de agosto de 2022 (fl. 94), deu-se a regular instrução do processo.

Durante a instrução processual ouviram-se duas testemunhas de acusação e, ao final, promoveu-se o interrogatório da acusada (fl. 161).

Em seguida as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, nos termos da denúncia, certa de que as provas dos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fls. 165/171).

A defesa pugnou pela absolvição embasada na ausência de provas da autoria, a par da fragilidade dos depoimentos colhidos, além de postular, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico em sua forma privilegiada (fls. 201/220).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito de tráfico está plenamente comprovada.

Os laudos de exame químico toxicológico (fls. 112/126) descreveram e concluíram que as substâncias analisadas são cocaína, maconha e cloreto de metileno, caracterizadas por meio de análises químicas e cromatográficas.

Pelos testemunhos dos autos a autoria também se evidenciou, não obstante as escusas inconvincentes da acusada, que em seu interrogatório judicial negou a prática da infração.

Susan declarou que na ocasião dos fatos saiu de sua casa para procurar seu filho.

Quando retornou, deparou-se com o entorpecente em sua residência. Argumentou que provavelmente dois indivíduos que encontrou correndo pelo prédio teriam deixado aquele material em sua casa, contra a sua permissão.

Vejamos um trecho de seu interrogatório:

“Eu saí por volta de nove e meia, mais ou menos, quinze pras dez, atrás do meu filho, porque eu deixei ele ir na casa de uma vizinha jogar videogame. E eu fui atrás dele pra chamar ele pra dentro, fui lá no salão de festas, fui dar uma olhada se as luz tava apagada, se não tinha cadeado estourado, eu tinha muito problema com essas coisas. E eu peguei e voltei. Quando eu voltei que eu entrei no bloco, eu encontrei com dois indivíduos correndo, eu virei a escada e subi. A minha casa normal, a minha porta tava aberta. Porque como eu achei que eu ia voltar logo, eu deixei aberta. Quando eu entrei, essas coisas tava na minha sala, senhor. Eu fiquei sem reação. Não sabia o que fazer. Eu pensei até em chamar a polícia, alguma coisa, mas quando eu vi a polícia já tava batendo na minha porta, já tinha tocado a campainha. Eu só tive, a única reação que eu tive foi de pegar e jogar no quarto”. Sua escusa não convenceu e restou isolada.

Primeiro porque ela não identificou as supostas pessoas que teriam deixado o entorpecente em sua residência.

Ora, sua versão de que pessoas desconhecidas teriam abandonado a droga em sua casa, sem que ela soubesse, afronta o raciocínio lógico deste Juízo.

Desta forma, desacreditadas suas palavras, em especial diante do acervo que se reproduzirá adiante.

Em brilhante decisão, da lavra do Des. José Raul Gavião de Almeida, que tomamos da liberdade de reproduzir, o Tribunal de Justiça de São Paulo apontou que a versão do acusado, quando esposada, deve ser comprovada para merecer confiabilidade.

“A regra insculpida no artigo 5º, inciso LXIII, da Constituição Federal (“o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado”) assegura ao acusado o direito ao silêncio, que tem dupla faceta.

Garante que o interrogando não seja forçado a pronunciar-se afastando definitivamente a prática da obtenção de informação contra a vontade de quem

responde criminalmente em persecução penal e obsta a valoração prejudicial ao réu do exercício desse direito de calar-se.

Houvesse a possibilidade de extrair prejuízo à defesa pela escolha do permanecer silente no interrogatório, essa preferência não caracterizaria um direito, mas teria a natureza jurídica de mera faculdade.

Uma vez optado por apresentar versão sobre os fatos, todavia, o interrogatório passa a integrar o conjunto probatório e, consequentemente, fica sujeito à valoração, seja benéfica ou maléfica aos interesses da defesa.

Em outras palavras, a regra constitucional do respeito ao silêncio deixa de ter relevância com o efetivo exercício da autodefesa, do direito de ser ouvido pelo juiz sem interposta pessoa. A preferência do acusado pelo pronunciamento em interrogatório acarreta a obrigação do magistrado de ouvi-lo e de valorar a versão que apresentar, beneficiando-o ou prejudicando-o, na medida em que a palavra do acusado, como as demais colhidas em juízo, não está imune ao princípio da persuasão racional.

Assim, se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor.

É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexatidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a inverdade".

Ao depois, durante a etapa policial ela admitiu que dois moradores do prédio onde reside a teriam coagido guardar o entorpecente (fl.9). Nada existe nos autos que possa invalidar o interrogatório realizado na fase policial.

Quanto ao bordão, comumente assacado nestas situações, de que teria havido coação policial, restou como mera ilação, sem qualquer elemento que lhe dê credibilidade, como seria ônus da ré, pois que se presume a licitude da conduta da autoridade policial, que nenhum motivo teria para incriminar o acusado.

Pertinente ao tema, há muito vem decidindo o Egrégio Supremo Tribunal Federal que: "a confissão feita no inquérito, embora retratada em Juízo, tem valia desde que não elidida "por quaisquer indícios ponderáveis, mas, ao contrário, perfeitamente ajustável aos fatos apurados" (Rcrim 1.261, DJU 2.4.76, p. 2225, apud CPP, Damásio, art. 197).

Somente em Juízo ela se retratou e apresentou nova versão sobre os fatos. Ora, sua retratação se revelou sem qualquer justificativa, salvo aquela aparente aos olhos de todos, de pretender a exclusão de sua responsabilidade criminal.

Gize-se, ainda, que durante a diligência policial, os policiais apreenderam diversos materiais normalmente utilizados no embalo e armazenamento de drogas, tais como diversas embalagens plásticas, além de anotações indicativas do seu envolvimento no comércio ilícito de drogas (fls. 34/36).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas, e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes - Não se pode negar valor aos depoimentos dos guardas municipais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL MAIS BRANDO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - IMPOSSIBILIDADE - Existindo nos autos evidências de não se tratar o réu de pequeno traficante, não se pode cogitar da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como da fixação de regime inicial diverso do fechado. Recurso parcialmente provido, somente para reconhecer a circunstância atenuante da menoridade relativa, porém, sem repercussão na pena final. (TJSP; Apelação 0002855-33.2017.8.26.0526; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 2ª Vara; Data do Julgamento: 23/08/2018; Data de Registro: 28/08/2018).

APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06 E ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/03. Absolvição por falta de provas para o crime de

tráfico - inocorrência - materialidade e autoria delitivas comprovadas - apreensão de variedade e expressiva quantidade de drogas na residência do recorrente, bem como a arma de fogo - circunstâncias da prisão do recorrente que atestam a prática de tráfico. Penas aplicadas de forma motivada, dentro dos parâmetros legais. Regime fechado é o correto diante da gravidade concreta dos crimes. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 0001123-48.2017.8.26.0548; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Cosmópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 14/08/2018; Data de Registro: 23/08/2018)

No mais, ela se escusou da imputação por meio de simples negatória geral, sem indicar por quais motivos poderiam os policiais querer lhe imputar injustificadamente crime de tamanha gravidade.

Se não bastasse a força de convencimento nesses elementos, corroboram a certeza da autoria os depoimentos seguros e harmônicos das testemunhas ouvidas durante a instrução. Senão vejamos.

O Policial Militar Jefferson relatou que recebeu denúncia anônima indicando que uma mulher residente no bairro do Enedina Cortez, apartamento 23, teria recebido grande quantidade de drogas. Diante disso rumou ao local indicado na denúncia. Lá chegando, deparou-se com a acusada e, ao informá-la sobre a suspeita de armazenamento de drogas, ela prontamente admitiu que dois indivíduos haviam pedido a ela para que guardasse o entorpecente em seu apartamento.

Diante disso, vistoriou o apartamento da acusada e, num dos quartos do imóvel, localizou grande quantidade de drogas, além de dois galões contendo lança-perfume. Finalizou acrescentando que no local também havia uma faca com resquícios de corte de drogas e diversos apetrechos utilizados no embalo do entorpecente.

Eis suas palavras:

D: (...) na ocasião estávamos em patrulhamento da Força Tática pelo município de Bragança Paulista, precisamente ali no bairro do Enedina Cortez, onde o COPOM passou pra, pela via rede rádio, pra viatura do setor, ir averiguar um possível tráfico de drogas no referido condomínio né. No bloco 1, apartamento 23, se não falha a minha memória. Onde descrevia que os indivíduos que teriam deixado três mochilas com drogas naquele apartamento, e descreveu a proprietária do apartamento como uma senhora magra, alta, uma mulher magra, alta, e as vestimentas que estava trajando naquele momento, naquela circunstância. Como eu estava próximo eu falei pros policiais, vamos averiguar isso aí. Me desloquei até o referido condomínio. Adentramos ao bloco. E toquei a campainha do apartamento né? Onde abriu a porta a proprietária, uma senhora, pude observar que estava uma senhora, e uma criança. E de pronto eu indaguei ela a respeito né? Falei pra ela, oh a gente acabou de receber informação que os indivíduos daqui do bairro deixaram três mochilas com drogas aí. Ela olhou pra mim e falou "olha, eles pediram pra guardar", indicando onde estaria a droga, franqueando a nossa entrada no imóvel. A droga estava acondicionada no, é um apartamento né, com dois quartos, a droga estava acondicionada no primeiro quarto, onde após a abertura da porta, ela mesma abriu, essa porta estava trancada com chaves né? É um quarto onde ela guardava uns pertences, tralhas, estava muito bagunçado o quarto. Na abertura da porta já sentimos aquele forte odor característico de maconha, e ela indicou onde estava a maconha. Ali dentro pude observar em cima de uma pequena escrivaninha, uma mesa que estava ali no canto da parede, dois galões com um líquido dentro, ao cheirar pude notar que se tratava também do conhecido, o pessoal usa né, conhecido loló, que o pessoal costuma usar em festas né, em raves. Continuando a busca, localizei mais grande quantidade de substância análoga à cocaína né, tanto em pinos né, acondicionadas em pinos né, que são os eppendorfs, como em saquinhos plásticos, bem como mais farta quantia de maconha já acondicionada, pronta pro comércio. Dois tijolos, dois "toupies", não me recordo bem agora, de maconha, bruto, pedra bruta, e vários apetrechos utilizados né pra acondicionar essas substâncias né, como sacolinhas, uma faca com vários resquícios de corte né, que eles usam pra cortar a maconha. Então diante das evidências né, dei voz de prisão pra dona do imóvel, chamei o apoio".

Suas palavras são confirmadas pelo PM Alberto, que de forma séria e coerente narrou a existência de denúncia anônima em face da acusada e do local em que ela residia,

bem como certificou o encontro das drogas no imóvel objeto da denúncia. Ao final, asseverou que a acusada confirmou informalmente a guarda das drogas em sua casa. Nada existe nos autos a demonstrar que os policiais responsáveis pela prisão da acusada tivessem qualquer motivo para imputar a ela, indevidamente, a prática de crime, em especial da gravidade do denunciado. Por seus conteúdos, eles são suficientes a comprovar a situação de traficância.

Por isso mesmo, a intenção de comerciar fica consubstanciada visto que tais provas apontam claramente para esta finalidade da agente. Não há nada que possa desabonar o depoimento dos policiais envolvidos, pois seus atos presumem-se legítimos por força de princípio administrativo.

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese do desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito".

Destarte, o argumento de que seus depoimentos estariam comprometidos pelo fato de terem o dever legal de justificar sua atividade não pode ser aceito. Se o fosse, estaria estabelecido preconceito odioso em relação a pessoas que auxiliam a justiça na busca da verdade real.

Assim, seus depoimentos são analisados e cotejados com os demais elementos carreados aos autos, sem maior ou menor relevância pelo fato de serem agentes de segurança do Estado, responsáveis pela repressão ao crime.

Neste diapasão, tem se manifestado a jurisprudência ao tratar do depoimento policial. Veja-se:

"A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita" (STF - RT 68/64).

"Não existe motivo algum a ensejar a desvalia do depoimento policial. Seria contra-senso credenciar o Estado alguém para atuar em seu nome e, depois, negar-lhe crédito, quando, perante o mesmo Estado juiz, viesse relatar seus atos de ofício. Por isso, totalmente superada a tese dos desprestígio do relato policial na moderna jurisprudência. O agente de segurança é testemunha como as demais. Submete-se a compromisso e terá seu depoimento avaliado no cotejo de todas as provas sem plus-valia, mas também sem preconceito" (Tacrím/SP - JUTACRIM 30/221).

Repise-se, assim, que os depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante são harmônicos e uníssonos. Frise-se também que ambos agentes públicos em seus depoimentos esclareceram, sem nenhuma contradição entre eles, o ocorrido naquela ocasião, inclusive com riquezas de detalhes demonstrando toda a operação realizada desde a chegada ao local, a abordagem policial e revista ao imóvel, não havendo, em princípio, nada que desabone esses depoimentos.

Nesta esteira:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PROCESSO PENAL - PROVA -DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - IDONEIDADE - RECONHECIMENTO. É idônea a prova testemunhal colhida, constituída do depoimento dos policiais que efetuaram a diligência. (TJ-SP - APL: 993061147033 SP, Relator: Willian Campos, Data de Julgamento: 04/05/2010, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/05/2010)

APELAÇÃO. INVIOABILIDADE DO DOMICÍLIO. PRELIMINAR AFASTADA. CRIME PERMANENTE. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIAS E MATERIALIDADES COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. "RES FURTIVA" APREENDIDA EM PODER DOS RÉUS. ÔNUS PROBATÓRIO. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE MODO ESCORREITO. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO. 1. A garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito. Tendo em vista que os crimes de tráfico de drogas e posse ilegal de munição de uso restrito têm natureza de "crimes permanentes", admite-se a prisão em flagrante sempre, ainda que esta prisão seja realizada no interior de uma residência. Precedentes do STF. 2. As autorias e as materialidades dos crimes de tráfico de drogas e roubos, um majorado e outro simples, restaram devidamente

comprovadas. Substâncias entorpecentes encontradas na casa do réu e os objetos roubados encontrados em sua posse. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito. Precedentes do STF e do STJ. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. 12. O instituto da detração, para ser aplicado, depende da análise da situação processual do sentenciado, inclusive no que concerne a eventuais condenações e unificação de penas. Portanto, o Juízo das Execuções Penais é a sede mais adequada para a apreciação da matéria. 13. Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00628017920128260050 SP 0062801-79.2012.8.26.0050, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 15/12/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 20/01/2015)

APELAÇÕES. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DOS RECURSOS DEFENSIVOS. 1. As autorias e a materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico restaram devidamente comprovadas, não só porque a substância entorpecente foi encontrada na posse de um dos réus, como também porque restou comprovado o vínculo associativo entre ambos os dois para fins da prática, reiterada ou não, do comércio espúrio, mercê de provas idôneas e suficientes para as suas responsabilizações. 2. Depoimentos dos policiais militares harmônicos e uníssonos no sentido da responsabilização criminal dos réus. Validade dos seus depoimentos, mormente quando submetidos ao crivo do contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o crime. 3. Dosimetria da pena fixada de modo correto. 4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, órgão constitucionalmente competente para tanto. Ademais, "in casu", o regime fixado continua sendo o fechado, mercê da pena imposta aos réus, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal. 5. Improvimento dos recursos das defesas. (TJ-SP - APL: 00015180220118260370 SP 0001518-02.2011.8.26.0370, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 14/04/2014, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 15/04/2014) Por outro lado, não foram ouvidas testemunhas de defesa capazes de descaracterizar as provas orais colhidas.

A finalidade de traficar está bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga encontrada, o local e as circunstâncias como foi surpreendida, tudo indica para uma guarda com a intenção de tráfico, venda.

A delação também deve ser levada em consideração porque jamais os policiais encontrariam a droga e investigariam a situação de traficância se não possuíssem informação confiável.

As denúncias anônimas são importantes fontes de informações para a polícia e, quando são confirmadas as delações com elementos concretos nos autos, merecem guarda para sustentar a acusação de tráfico de entorpecentes, pois não se pode esperar que a pessoa delatora de tão grave delito assuma sem temor sua identidade, ante a usual represália emanada dos inúmeros traficantes de drogas que mutuamente se ajudam.

No mais, a apreensão de apreciável quantidade de substância entorpecente, conduz à segura conclusão de estar configurado o delito de tráfico.

O crime de tráfico ilícito de drogas traz em seu tipo penal vários verbos que exprimem as formas de conduta puníveis, algumas de natureza instantânea, outras permanentes, não sendo necessário para sua configuração tenha a agente efetuado a

venda. Basta que a possua ou tenha em depósito com o fim de colocá-la em circulação, incorrendo, assim, em uma das figuras do tipo.

Em escólio à norma em apreço, o renomado VICENTE GRECO FILHO leciona a respeito da prescindibilidade da ocorrência da venda do produto, assim asseverando:

"Para a existência do delito não há necessidade de ocorrência do dano. O próprio perigo é presumido em caráter absoluto, bastando para a configuração do crime que a conduta seja subsumida num dos verbos previstos" (Tóxicos - Prevenção - Repressão. Saraiva, 1987, p. 81.)

A esse respeito, esclarecedor é o seguinte julgado:

"Para a consumação do delito de comércio clandestino de entorpecente, não importa que o produto não tenha sido distribuído à venda. Consuma-se ele embora não tenha resultado o dano. Seu não-exaurimento, porém, é irrelevante, vez que não, ficou afastada a real periclitación do bem jurídico penalmente protegido. Nem se há de falar na hipótese de crime impossível." (RT 401/75)

Nas modalidades que configuram crime permanente, ou seja, expor à venda, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, etc... evidenciado o início da execução, tem-se o crime por consumado.

A propósito, os ensinamentos do ilustre doutrinador MENA BARRETO, que bem demonstram o entendimento pacífico sobre a matéria:

"Afim, cabe nesta oportunidade lembrar, igualmente, algumas ações delituosas que têm caráter formal ou de consumação antecipada e que por via de consequência, dada a sua não-fragmentação, desautorizam a aceitação de tentativa. É o caso, verbi gratia, das relativas à guarda, ao depósito ou ao transporte de tóxicos, além da simples posse (trazer consigo)" (Lei de Tóxicos, Comentários por Artigo. Freitas Bastos, 1996, p. 74.).

Ora, a conduta praticada pela acusada amolda-se perfeitamente às figuras "guardar e ter em depósito", previstas no tipo penal do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, bem comprovadas a autoria e materialidade da infração, ficando sem guarida as combativas alegações da defesa.

O argumento da acusada exarado na etapa policial de que apenas teria aceitado guardar as drogas porque fora coagida por dois indivíduos não é suficiente para livrá-la da condenação com o consequente reconhecimento da excludente de culpabilidade (inexigibilidade de conduta diversa).

Primeiro porque não existem provas sobre a alegada situação, ônus que competia à defesa. Segundo porque, sob a conformação legislativa, as hipóteses de inexigibilidade de conduta diversa amoldam-se aos casos de coação moral irresistível e obediência hierárquica a ordem não manifestamente ilegal, nos termos do artigo 22, do Código Penal, hipóteses diversas da presente.

De acordo com o finalismo - teoria normativa pura da culpabilidade-, não há culpabilidade todas as vezes que, tendo em vistas as circunstâncias do caso concreto, não se possa exigir do sujeito uma conduta diversa daquelas por ele cometida. Assim, a exigibilidade de conduta diversa constitui elemento da culpabilidade, enquanto a não exigibilidade constitui a razão de algumas causas de exclusão da culpabilidade.

A exigibilidade parte do princípio que só podem ser punidas as condutas que podem ser evitadas. Ora, o fato da acusada supostamente ter sido ameaçada por um traficante e coagida a guardar as drogas certamente não se inclui como justificante para a prática do crime.

"A censura de culpabilidade pressupõe tenha podido o autor formar sua resolução de ação antijurídica mais corretamente, ou seja, de acordo com a norma. E isto não em um sentido abstrato de "algum homem" no lugar do autor, mas no mais concreto sentido de que "este homem, nesta situação", tenha podido formar sua resolução de vontade de acordo com a norma".

Na espécie, poderia certamente a acusada ter se comportado de maneira diversa.

Destarte, sem amparo a alegação de que a acusada não podia agir de maneira diversa.

Nesta esteira:

HABEAS CORPUS Nº 425.775 - SP (2017/0301735-3) RELATOR : MINISTRO JORGE MUSSI

IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO ADVOGADO : MENESIO PINTO CUNHA JUNIOR - SP149434 IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO PACIENTE : ARNALDO DE ALMEIDA PACIENTE : MARCELO GABRIEL OSORIO DECISÃO: O TJSP negou provimento à apelação da defesa com os seguintes termos (e-STJ, fl. 81): [...]. A esta altura, insta frisar que a alegação de que o delito se deu mediante coação moral irresistível não se mostra suficiente para isentar de responsabilidade o acusado Arnaldo, uma vez que tal circunstância não restou comprovada na instrução contraditória. A coação irresistível, além de reclamar prova indubitosa, a cargo da defesa, exige, no plano moral, a existência de uma intimidação concreta e exterior ao agente. A propósito: A alegação de coação irresistível exige demonstração de prova indubitosa a cargo da Defesa, sendo insuficiente para elidir a acusação a simples argumentação de sua ocorrência, presumindo a existência do coator para quem é transferida a responsabilidade criminal (Rel. SILVEIRA LIMA RJTACRIM 55/78). Inadmissível o reconhecimento da excludente da coação irresistível quando não comprovada em todos os seus requisitos, máxime tendo o agente participação ativa e independente na execução do crime (Rel. HAROLDO LUZ RJDTACRIM 11/144). A coação, para ser reconhecida como excludente, há que ser cumpridamente comprovada. Nessa sede, alegar e não provar se equivalem (Rel. FERNANDES DE OLIVEIRA RJTACRIM 39/87). Brasília (DF), 20 de setembro de 2018. MINISTRO JORGE MUSSI Relator (STJ - HC: 425775 SP 2017/0301735-3, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Publicação: DJ 26/09/2018).

APELAÇÃO - Condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006) - Materialidade e autoria devidamente demonstradas - Credibilidade das palavras das agentes de segurança - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório - Pretensão ao reconhecimento do crime impossível - Inadmissibilidade - Crime de tráfico de drogas de natureza permanente - Crime consumado - Pretensão ao reconhecimento de causa de exclusão da culpabilidade - Impossibilidade - Coação moral irresistível não demonstrada - Dosimetria das penas esboçada - Sentença mantida - Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 15029748420178260536 SP 1502974-84.2017.8.26.0536, Relator: Cláudio Marques, Data de Julgamento: 08/08/2019, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/08/2019).

APELAÇÃO. Tráfico de drogas em estabelecimento prisional. Recurso defensivo. Absolvição por insuficiência probatória. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem demonstradas. Confissão do réu em harmonia com os demais elementos probatórios coligidos aos autos. Reconhecimento da excludente de culpabilidade da coação moral irresistível. Impossibilidade de atuação de acordo com o ordenamento jurídico não demonstrada. Condenação mantida. Pena e regime bem fixados. Recurso improvido. (TJ-SP - APR: 00007772220188260594 SP 0000777-22.2018.8.26.0594, Relator: Leme Garcia, Data de Julgamento: 10/07/2019, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 10/07/2019).

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade da conduta praticada pela condenada não justifica aumento nas penas-base.

Ela não ostenta antecedentes criminais e os autos não fornecem elementos seguros para análise da conduta social e da personalidade da agente.

Os motivos e consequências do crime não diferenciam, quando comparados com outros da mesma espécie, estes fatos de outros praticados em situações semelhantes, não merecendo assim, este, maior reprovabilidade. Não há participação de vítima no tráfico a ser considerada na dosimetria da pena.

No entanto, levando em consideração as circunstâncias do crime, a par da quantidade da droga apreendida, em obediência ao teor do artigo 42, da Lei 11.343/2006, vemos que as penas-base comportam acréscimo por conta deste fator.

Presente a circunstância judicial acima exposta, que deve levar à exacerbação das penas-base, fixo-as em 7 (sete) anos de reclusão e 700 dias-multa no patamar mínimo

legal.

Na segunda etapa, inexistem circunstâncias atenuantes ou agravantes a considerar. Na etapa final, não foram observadas causas de aumento de pena.

A acusada é primária, portadora de bons antecedentes criminais e, nestes autos, não se demonstrou que ela tenha envolvimento ou integre organização criminosa. Logo, amolda-se na hipótese da aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06.

Assim sendo, suas penas serão diminuídas em 1/6, pois não existem motivos a justificar maior redução em virtude da quantidade da droga apreendida (7 anos - 1/6 = 5 anos e 10 meses/700 dias - 1/6 = 583 dias-multa).

Não obstante recente entendimento do Supremo Tribunal Federal quanto ao reconhecimento da desconsideração da hediondez ao tráfico privilegiado, o que possibilitaria o cumprimento inicial de pena em regime mais brando, in casu, ante a quantidade da droga apreendida em poder da condenada, aproximadamente 800 porções de cocaína e mais de um quilo de maconha, drogas essas que possuem elevado poder viciante, o regime inicial será o fechado, visto que, qualquer outro regime não contribuiria para a reprovação do crime e ressocialização da agente.

Nessa esteira:

EMBARGOS INFRINGENTES - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, NA MODALIDADE PRIVILEGIADA - DISCUSSÃO ENVOLVENDO O REGIME PRISIONAL CABÍVEL E A APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS - BENEFÍCIOS INAPLICÁVEIS NA ESPÉCIE - RÉU QUE TRAFICAVA, ALÉM DE MACONHA, TAMBÉM COCAÍNA, DROGA ESTA DE EFEITOS NEFASTOS À SAÚDE DE USUÁRIOS E VICIADOS - NECESSIDADE DE ENÉRGICA REPROVAÇÃO - ALTA REPROVABILIDADE DA CONDUTA, QUE JUSTIFICA A RECUSA DOS BENEFÍCIOS, A DESPEITO DA NÃO-HEDIONDEZ DO CRIME - RECURSO DESPROVIDO. (EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 0100260-13.2015.8.26.0050/50000 Comarca: SÃO PAULO - Processo nº 0100260-13.2015.8.26.0050 Juízo de Origem: 8ª Vara Criminal Órgão Julgador: 4ª Câmara de Direito Criminal Embargante: LUCAS SANTANA BATISTA Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRITÉRIO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. REGIME FECHADO. NECESSIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Embora não hediondo o crime de tráfico privilegiado, a quantidade e qualidade da droga obstam a fixação do regime mais brando. 3. Negado provimento ao recurso. (APR 10702100791806001 MG Órgão Julgador: Câmaras Criminais Isoladas / 7ª CÂMARA CRIMINAL. Publicação: 11/01/2013. Julgamento: 13 de Dezembro de 2012. Relator: Marcílio Eustáquio Santos).

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese. Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nesses termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via. Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

A condenada não poderá apelar em liberdade, uma vez que o Juízo ainda vislumbra como presentes requisitos da prisão cautelar a teor da decisão anterior que manteve sua custódia, reforçados pelos argumentos desta condenação e pela Súmula nº 9, do Superior Tribunal de Justiça. Nessa esteira:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. APELO EM LIBERDADE. RÉ QUE PERMANECEU PRESA DURANTE O CURSO DA AÇÃO PENAL. DECRETO PRISIONAL MOTIVADO. RECURSO DESPROVIDO. 01. Não há 'ilegalidade ou abuso de poder' (CR, art. 5º, inc. LXVIII), de modo a autorizar a concessão do habeas corpus, na decisão que, fundamentadamente, descreve a gravidade dos fatos delituosos imputados ao réu e indica a necessidade da manutenção da prisão cautelar (STJ, RHC 52.700/SP, Quinta Turma, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 11/12/2014; HC 294.499/DF, Sexta Turma, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/08/2014; STF, RHC 116.964, Primeira Turma, Rel. Ministro Rosa Weber, DJe de 18/11/2013, HC 124.994, Segunda Turma, Rel. Ministro Teori Zavaski, DJe de 18/12/2014).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR SUSAN PEREIRA DA SILVA, qualificada nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e mais 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica.

Recomende-se na prisão onde ela estiver.

Concedo à sentenciada os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.

Com o trânsito em julgado, promovam-se as comunicações de praxe e adote o necessário ao cumprimento da pena.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 14 de dezembro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA